

第 58 問

以下の小問における甲、乙及び丙の罪責について、論じなさい。なお、(1)において、住居等侵入罪については検討する必要がある。

- (1) 甲は、金に困っていたため、振り込め詐欺により、金員を得ようと考えた。そのためには、まず通帳やキャッシュカード（以下、通帳とキャッシュカードを総称して「通帳等」という。）が必要であると考えた甲は、自己の舎弟であり何でも言うことを聞く乙に対して、「乙名義の銀行口座を新しく作って、俺に使わせてくれ。」と頼んだ。

乙は、これを受けて、A銀行の窓口へ行き、担当者に対して、甲に使用させることを秘し、新規口座の開設を依頼し、担当者をして、乙名義の口座を開設させ、同人からA銀行の通帳等の交付を受け、これを甲に手渡した。なお、A銀行の取引約款において預金口座、預金債権の譲渡等は一切禁じられている。

その後、甲は、電話帳で調べたB宅へ電話をかけ、「あー、お母さん。俺だよ、俺。さっき、バイクで事故を起こしちゃって、相手に怪我をさせちゃったんだ。相手の人は今日中に100万円振り込まないと警察へ通報すると言っているんだ。すまないけど、今から言う口座番号に100万円を振り込んでくれないか。」などと嘘をつき、A銀行の乙名義口座の口座番号を教えた。これを信じたBは、甲の指示どおりに、同口座に100万円を振り込んだ。

翌日、甲は、A銀行のATMを操作して、Bが振り込んだ現金100万円を引き出した。

- (2) 丙は、Cが留守の間にC宅へ立ち入り、A銀行のC名義の通帳等と暗証番号が書かれているメモを見つけた。丙は、A銀行の通帳に現金約300万円が預金されている旨の記録があったことから、通帳等を着衣のポケットに入れた。その後、丙は、これらを用いて現金を引き出そう考え、まずは預金残高を確認するため、A銀行の店舗外に設置されているATMを操作し、残高照会のボタンを押した。ATMの画面の指示に従って、丙がメモに記載されていた暗証番号を入力したところ、その暗証番号は別の銀行口座のものであったため、丙は残高照会を行うことができなかった。そのため、丙は仕方なくATMを後にした。

第1 乙の罪責（小問(1)）

- 1 譲渡目的を秘して自己名義の口座を開設した行為について、詐欺罪（246 I）が成立するかを検討することになる（**論点** 銀行取引と財産罪③～口座開設）。
- 2 そもそも、預金通帳に財物性が認められるかという問題があるも、最決平14.10.21は「預金通帳は、それ自体として所有権の対象となり得るものであるにとどまらず、これを利用して預金の預入れ、払戻しを受けられるなどの財産的な価値を有するものと認められるから、他人名義で預金口座を開設し、それに伴って銀行から交付される場合であっても、刑法246条1項の財物に当たる」として、これを肯定している。キャッシュカードについても、財物性が認められている（最決平19.7.17等）。
- 3 そして、欺罔行為については、前掲最決平19.7.17が「銀行支店の行員に対し預金口座の開設等を申し込むこと自体、申し込んだ本人がこれを自分自身で利用する意思であることを表しているというべきであるから、預金通帳及びキャッシュカードを第三者に譲渡する意図であるのにこれを秘して上記申込みを行う行為は、詐欺罪にいう人を欺く行為にほかならず、これにより預金通帳及びキャッシュカードの交付を受けた行為が刑法246条1項の詐欺罪を構成することは明らかである。」として、これを肯定した。これに従えば、A銀行に対する1項詐欺罪が成立することになる。

総合 249 頁 論証 125 頁

第2 甲の罪責（小問(1)）

- 1 乙による口座開設行為に関しては、共同正犯（60）としてよいだろう（**論点** 共同正犯の成立要件（共謀共同正犯論）  H20,H24,H27,H28,H29,R3,予H24,H27,旧H7-1,H14-1,H15-1,H18-1）。甲は口座及び通帳の詐取の計画者であるし、通帳の交付を受け、その経済的利益を得ているからである。
なお、仮に教唆犯と解した場合には、通帳の交付を受けた行為は、盗品等無償譲受け罪になる（256 I）。
- 2 Bに対してした行為であるが、振り込め詐欺については、1項詐欺罪として処理し、自己の支配、管理する口座に振り込ませた時点を既遂とするのが裁判例の傾向である（大阪高判平16.12.21）（**論点** 銀行取引と財産罪①～振り込め詐欺（恐喝）  司R2,予H25,旧H7-2,H11-2,H18-2）。
なお、本件は、乙名義の口座であり、自己名義の口座でないことが問題にはなるが、上記大阪高判は、架空名義人の口座に振り込ませたという事案において、「本人に成りすますなどして銀行側を欺く必要があることは確かであるが、そうしたことは、既に同口座を開設し管理していた被告人らにとってさほど困難なことではないし……、被告人らが本件預金口座から預金を引き出すことについて障害となるような事情のなかったことも明らかである。」として、振り込ませた時点で既遂としており、本問も同様に考えてよいだろう。
- 3 甲がA銀行のATMを操作して、Bが振り込んだ現金100万円を引き出した行為であるが、甲は乙名義の通帳を管理下に置いていたとはいえ、預金口座、預金債権等の譲渡が禁じられており、正当な払戻権限がない以上、意思に反する占有移転があるとして、窃盗罪（235）の成立

総合 139 頁 論証 55 頁

総合 247 頁 論証 120 頁

を肯定してよい（東京高判平17.12.15参照）。

- 4 なお、預金口座開設にかかるA銀行に対する1項詐欺罪、預金の引き出しにかかるA銀行に対する窃盗罪については、別罪を構成すると解すべきである。

判例（最決平14.2.8）は、本問とは事案が異なるものの、ローンカードを詐取した後、ATMで現金を引き出した行為について、欺罔行為によって消費者金融を営む会社にローンカードを「交付させる行為と、同カードを利用して現金自動入出機から現金を引き出す行為は、社会通念上別個の行為類型に属するものである」というべきである。……ローンカードの交付を担当した同社係員は、これらの行為により、上記無人契約機コーナー内に設置された現金自動入出機内の現金を被告人に対して交付するという処分行為をしたものとは認められず、被告人は、上記2のような機能を持つ重要な財物である同カードの交付を受けた上、同カードを現金自動入出機に挿入し、自ら同機を操作し作動させて現金を引き出したものと認められる。したがって、被告人に対し、同社係員を欺いて同カードを交付させた点につき詐欺罪の成立を認めるとともに、同カードを利用して現金自動入出機から現金を引き出した点につき窃盗罪の成立を認めた原判決の判断は、正当である。」として、別途窃盗罪が成立するとしている。同決定は罪数関係について明らかにしていないが、調査官解説は併合罪としたものという理解をしている。

本問においても、上記各罪は、社会通念上連続性が乏しく、別個の行為であるというべきであるから、併合罪とするのが良いように思われる。

第3 丙の罪責（小問(2)）

- 1 丙がC宅に立ち入った行為につき、住居侵入罪（130前段）、C名義の通帳をポケットに入れた行為について、窃盗罪（235）が成立することとは問題ない。
- 2 問題は、Cのキャッシュカードや通帳を用いて、これを引き出そうとした行為である（**論点** 銀行取引と財産罪④～キャッシュカード（ローンカード）の詐取（窃取）と預金の引き出し **論** 予H25,旧H5-2）。
- (1) 甲が残高照会を行おうとした時点では、暗証番号が異なることから、いわゆる不能犯の問題が生じる。不能犯について、どのような立場に立つかによるところはあるが、本問事実関係の下では、多くの見解からは不能犯とはならないだろう。
- (2) また、この時点で預金の占有移転にかかる危険性及び同行為に密接性が認められるから、「実行」の「着手」（43本文）が公定される（残高照会の時点で実行の着手を肯定したものとして、名古屋高判平13.9.17、京都地判平18.5.12がある。）。
- 3 なお、第2の4で検討したところからすれば、Cに対する窃盗罪とA銀行に対する窃盗未遂罪は併合罪となろう。

総合 250 頁 **論証** 123 頁

答案構成

第1 乙の罪責

1 A銀行に対する詐欺罪（246 I）の成否

↓

2 預金通帳やキャッシュカードは「財物」に当たる

↓

欺罔行為

↓

相手方が財産的処分行為をするための判断の基礎となるような重要な事項を偽ることをいうが、重要な事項とは、経済取引上なものに限られる

↓

あてはめ

↓

作為（挙動）による欺罔行為

↓

詐欺罪（共同正犯）成立

第2 甲の罪責

1 1項詐欺罪の共同正犯の成否

↓

共謀共同正犯

↓

意思連絡、正犯意思

↓

あてはめ

↓

2 Bに100万円を振り込ませた行為については、1項詐欺罪の成否が問題となる

↓

振込入金された時点でこれと同額の金員を自由に処分できる状態に置かれたとみることができる

↓

要件検討

↓

既遂時期は、振込入金時

↓

3 甲がA銀行のATMを操作して、Bが振り込んだ現金100万円を引き出した行為については、A銀行に対する窃盗罪（235）の成否が問題となる

↓

甲には正当な払戻権限がない

↓

A銀行に対する窃盗罪が成立する

- ↓
- 4 ① A 銀行に対する 1 項詐欺罪、② B に対する 1 項詐欺罪及び③ A 銀行に対する窃盗罪が成立し、全て併合罪（45前段）となる

第 3 丙の罪責

- 1 C に対する住居侵入罪（130前段）、窃盗罪（235）成立
- ↓
- 2 C の通帳等を用いて、A 銀行のATMを操作し、現金を引き出そうとした行為について A 銀行に対する窃盗未遂罪（243、235）の成否が問題となる
- ↓
- 3 不能犯
- ↓
- 具体的危険説
- ↓
- あてはめ
- ↓
- 実行の着手（43本文）
- ↓
- 危険性及び密接性の基準をもって判断する
- ↓
- あてはめ
- ↓
- 4 住居侵入罪、窃盗罪は牽連犯に（54 I 後段）、これと窃盗未遂罪は併合罪となる

第1 乙の罪責(小問(1))

1 乙がA銀行の担当者に対して、甲に使用させることを秘し、新規口座の開設を依頼し、担当者をして、乙名義の口座を開設させ、同人からA銀行の通帳等の交付を受けた行為について、「人を欺いて財物を交付させた」として、A銀行に対する1項詐欺罪(246条1項)の成立が考えられる。

2(1) まず、預金通帳は「財物」に当たる。預金通帳はそれ自体所有権の対象となるだけでなく、払戻しを受けられるなどの財産的価値を有するからである。キャッシュカードも同様である。

(2) もっとも、本件では、乙は口座を甲に使用させる目的を秘しているものの、自己名義で口座を開設していることから、「人を欺(く)」行為(欺罔行為)が認められないかにも思える。

欺罔行為とは、相手方が財産的処分行為をするための判断の基礎となるような重要な事項を偽ることをいう。もっとも、詐欺罪も財産罪であるから、重要な事項とは、経済取引上重要なものに限られる。

ここで、金融機関が約款をもって預金債権の譲渡を禁止しており、これに反する意図があると分かれば口座開設を謝絶するであろうこと、このような口座開設の謝絶が金融機関の信用性維持という観点から行われていることに鑑みれば、口座の自己使用目的があるか否かは、金融機関にとって、経済取引上の重要事項であるといえる。

したがって、上記重要な事項を偽ったといえる。

そして、譲渡目的を秘して口座を開設した行為は、それ自体口座を

1

自己使用目的で利用し続けるという意味の表明であると解されるから、作為(挙動)による欺罔行為を構成すると考える。

(3) 上記欺罔行為に基づいて、A銀行が錯誤に陥り、通帳等を交付するという財産的処分行為を行っているから、A銀行に対する1項詐欺罪が成立する。なお、後述の通り、甲と共同正犯(60条)になる。

第2 甲の罪責(小問(1))

1 乙に対し、乙名義の口座を開設するよう頼んだ行為について、A銀行に対する1項詐欺罪の共同正犯が成立しないか。

(1) 甲は、本件詐欺の実行行為を行っていないが、相互利用補充関係による共同犯行の一体性は、共謀共同正犯の場合にも当てはまるため、共同正犯者間に意思の連絡及び自らの犯罪として実行する意思を有している場合には、「共同して犯罪を実行した」として、これを「正犯」としてよい。

(2) 甲は、乙に対して乙名義の口座開設を依頼しており、乙もこれを承諾していることから、上記行為(犯罪)について、意思連絡は認められる。また、甲は乙名義の口座開設を自己が振り込み詐欺を行うために依頼しており、自らの犯罪として行う意思を有している。

したがって、甲はA銀行に対する1項詐欺罪の共同正犯となる。

2 Bに虚偽を申し向け100万円を振り込ませた行為については、1項詐欺罪を検討すべきである。振込みは経済取引上支払の決済手段として広く用いられており、通常は振込入金された時点でこれと同額の金員を自由に処分できる状態に置かれたとみることができるからである。

2